



PODER JUDICIAL DE CÓRDOBA

JUZGADO DE FAMILIA 5A NOM.

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 426

Año: 2024 Tomo: 5 Folio: 1291-1301

EXPEDIENTE SAC: xxx – O., J. L. C/ E., A. S. - DIVORCIO VINCULAR - CONTENCIOSO

PROTOCOLO DE AUTOS. NÚMERO: 426 DEL 25/07/2024

AUTO

Córdoba, veinticinco de julio de dos mil veinticuatro.

Y VISTOS: Estos autos caratulados “O., J. L. C/ E., A. S. - DIVORCIO VINCULAR - CONTENCIOSO” de los que resulta que:

1) Con fecha 24.9.2019 (fs. 326/329) y 26.11.2019 (fs. 338) J. L. O., con el patrocinio letrado de la abogada C. M. M., solicita se le atribuya de manera definitiva el inmueble que fuera vivienda familiar, al tratarse de un bien propio, por haber sido adquirido con anterioridad a contraer nupcias (art. 443 del CCC).

Relata que con fecha 01/06/2004 adquirió el inmueble, procediendo a realizar las respectivas obras en el terreno, argumentando que hasta el día 05/12/2009 no pudo haber convivido con la contraria, dado que la obra no estaba apta para habitarse, por lo que recién comenzó a vivir con E. con fecha 05/12/2009, solo una semana antes del nacimiento de su hija.

Añade que siempre se hizo cargo del pago de los impuestos que gravan el inmueble, y que sigue abonando los mismos, a pesar que hace 4 años la contraria vive en su propiedad, haciendo uso exclusivo y sin abonar una compensación.

Remarca que lo referido al cuidado parental de su hija, y lo referido a sus obligaciones económicas, ya se encuentran reguladas. Por ello, dado que se fijó una cuota alimentaria a su cargo en un porcentaje de sus haberes, y dado que dentro de la cuota alimentaria se encuentra incluido lo referido a proporcionar habitación a su hija, por lo que sostiene que la

contraria cuenta con una suma dineraria que le permite hacer frente a la erogación que pudiera implicar el alquiler de una vivienda. Por lo tanto, considera injusto que deba hacerse cargo de forma exclusiva del deber de aportar un lugar para que habite su hija.

Refiere que en virtud del art. 526 del CCC, la atribución de la vivienda puede realizarse con un límite temporal, que no puede ser mayor al que hubiere durado la convivencia, y un plazo máximo de 2 años. Por ello, advierte que ya se excedió el plazo máximo para otorgar la atribución del hogar, por lo que, en función de la medida provisoria de fecha 5.9.2018 (fs. 246/247) que resolvió mantener la situación habitación de E. y la hija y que no fijó un plazo, considera que existe una afectación de su derecho de propiedad, incompatible con la normativa constitucional.

Aclara que, de hacerse lugar a la acción solicitada, tal aspecto no implica sustraerse de la obligación habitacional en relación a su hija, para lo cual, se puede establecer un cuidado personal compartido, fijando domicilio principal el del progenitor, en el inmueble cuya restitución solicita. Ofrece prueba documental, confesional, testimonial. Peticiona se admita el incidente de atribución del inmueble sede conyugal con costas a la contraria.

Posteriormente, con fecha 29.9.2019 (fs. 330) este tribunal requirió al actor que precisara con exactitud los términos de lo peticionado (adjudicación o atribución del uso) y el actor precisó que requería la atribución en los términos del art. 443 del CCC (fs. 338).

Con fecha 16.3.2020 insta la continuación del trámite (fs. 344) y solicita una fijación a cargo de E. de una renta compensatoria hasta que le sea atribuido el inmueble como propio, por la suma equivalente al valor del canon locativo de un inmueble de similares características, el cual estima en \$9500. Asimismo, peticiona el cambio de modalidad del cuidado personal de su hija, a fin de que su hija continúe viviendo en el mismo inmueble, pero con su progenitor.

2) Con fecha 01/07/2020 se imprime el trámite previsto por el art. 75 de la ley 10305 a las peticiones formuladas de atribución del uso de la vivienda (art. 443 del CCC), fijación de canon locativo (art. 444 del CCC) y el cambio de cuidado personal de la hija (arts. 648 y sig. del CCC), mediante el cual se ordena correr traslado a A. S. E., quien contesta con fecha 21/08/2020 con el patrocinio del abogado M. A. R. (fs. 349/364 y 374/385). En tal presentación, solicita el rechazo de la solicitud de la contraria. Expresa que el inmueble fue adquirido en junio de 2004 cuando ya habían iniciado una vinculación sentimental. Afirma que su vida laboral transcurrió mayoritariamente en la informalidad, sin perjuicio de lo cual, realizó aportes para la construcción y equipamiento de la casa.

Por otro lado, sostiene que se debe reconocer el valor económico de las tareas de cuidado personal de su hija. Además de ello, reitera que además de haber efectuado contribuciones en efectivo, tanto la construcción como la totalidad de las necesidades y gastos comunes, fueron solventadas de forma conjunta.

Por otra parte, manifiesta que del certificado expedido por el juez de P. de Villa Allende, surge acreditada la convivencia de fecha 28/07/2008.

Agrega que su permanencia en el inmueble se debe a que ese siempre ha sido el hogar y centro de vida de su hija M. L.

En cuanto a la cuota alimentaria aportada por O del 35% del SMVM afirma que no alcanza para pagar el costo de un alquiler y además afrontar los gastos esenciales de su hija. Explica que no corresponde aplicar el plazo de 2 años de las uniones convivenciales (art. 526 del CCC) porque se trata de un matrimonio divorciado (art. 443 del CCC).

En conclusión, considera que se debe tener en cuenta el interés superior de ML de permanecer en la casa y viviendo con su mamá, por lo que solicita que se mantenga la atribución de la vivienda, con costas a la contraria.

Ofrece prueba documental, informativa, confesional, testimonial, y encuestas domiciliaria y ambiental.

3) Con fecha 18.5.2021 J. L. O. comparece con nuevo domicilio procesal con el abogado L. M. C.

4) Con fecha 30/08/2021 se fija audiencia en los términos del art. 81 de la ley 10305, la cual se desarrolla con fecha 10/11/2021, en la cual, las partes ratifican sus presentaciones, y la demandada ofrece prueba pericial. Seguidamente se provee a la prueba ofrecida por las partes en los siguientes términos: “... A mérito de las constancias de autos proveyendo a la prueba ofrecida a fs. 326/329, 338 y 344: *INSTRUMENTAL-DOCUMENTAL: téngase presente. CONFESIONAL: acompañe pliego de posiciones y se proveerá lo que por derecho corresponda. TESTIMONIAL: atento lo dispuesto por el art. 76 de la Ley 10.305 emplácese al Sr. O. para que en el término de tres días limite el número de testigos, denunciando en su caso los datos necesarios, bajo apercibimiento de hacerlo el tribunal de oficio. A la ofrecida a fs. 349/364 y readecuada en la audiencia: DOCUMENTAL: téngase presente. INFORMATIVA: oficiese. CONFESIONAL: acompañe pliego de posiciones y se proveerá lo que por derecho corresponda. TESTIMONIAL: a fin de recepcionar la declaración testimonial de los Sres. C. S. B., C. L. N. E. y F. H. E. fíjense las audiencias del día 17 de diciembre del año en curso, a las 9:30, 10:00, 10:30 y 11:00 horas, respectivamente, a la que deberán ser citados bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública. PERICIAL: previo a fijar audiencia para el sorteo de un perito psicólogo y un perito asistente social acompañe puntos de pericia y se proveerá lo que por derecho corresponda...*”. Proveído ampliado con fecha 24.11.2021 respecto a la testimonial y prueba pericial.

5) Con fecha 18/04/2023, se certifica el vencimiento del término probatorio (art. 86 del CPF) y atento el estado de la causa, se ordena correr traslado para alegar (art. 87 del CPF) a J. L. O., quien contesta de manera extemporánea.

Por su parte, con fecha 31/07/2023, la parte incidentada contesta el traslado para alegar y solicita se disponga la atribución del hogar a su favor para que lo siga habitando conjuntamente con su hija M. L. y se rechace el pedido de adjudicación del bien propio del actor.

6) Con fecha 31/07/2023 se ordena correr traslado a la representante complementaria, quien previamente solicita se fije audiencia a los fines de tomar contacto con M. L. Tal audiencia se desarrolla con fecha 22/08/2023, y conforme se certifica fue entrevistada por la Jueza Susana María Squizzato la adolescente M. L. O., en presencia la Auxiliar colaboradora de la Asesoría de Familia del Tercer Turno, Gabriela Soledad Mariani, en su carácter de representante complementaria y las licenciadas del CATEMU, A. P. y E. L.. Con fecha 29.8.2024 se incorpora el informe de las licencias del CATEMU. Corrido nuevo traslado, la Asesora de Familia del Tercer turno lo contesta con fecha 14/09/2023. En tal presentación, en primer lugar, considera que se debe mantener la modalidad del cuidado personal de la adolescente en el domicilio materno. Afirma que, si bien ha quedado acreditado en autos que la vivienda es de propiedad del progenitor, la misma ha sido sede del hogar conyugal y residencia principal de M. L. desde su nacimiento. Por ello, considera que la pretensión encuadra dentro del art. 443 del CCC. Agrega que E. se encuentra en la situación económica más desventajosa, dado que no cuenta con ingresos suficientes a fin de proveerse una vivienda. Por ello, estima que debe rechazarse la pretensión paterna de atribución del uso del bien y cambio del cuidado personal, además de mantenerse la cuota alimentaria establecida en autos, e igualmente el plan de parentalidad.

7) Dictado el proveído que ordena “Autos”, firme el mismo queda la cuestión en condición de ser resuelta por el Tribunal.

Y CONSIDERANDO:

1) LA COMPETENCIA:

La competencia de quien suscribe deviene de lo dispuesto por los arts. 16 inc. 2 y 7 y 21 inc. 1 de la Ley 10305 y arts. 716 y 717 del CCC.

2) LAS CUESTIONES A RESOLVER:

En primer lugar se aclara que las partes en sus relatos, como así en la prueba que ambos ofrecen, dirigen sus esfuerzos a acreditar los derechos sobre el inmueble que fuera sede de la vivienda conyugal, cuando en rigor de verdad debieron enfocarse sólo en las cuestiones a las que se le imprimió el trámite de ley (1.7.2020), esto es al pedido de atribución del uso de la vivienda (art. 443 del CCC), fijación de canon locativo (art. 444 del CCC) y el cambio de cuidado personal de la hija (arts. 648 y sig. del CCC). En efecto, aquí no se trata de la adjudicación del inmueble al incidentista y menos aún de establecer la contribución de la ex cónyuge en su adquisición o en la construcción de la vivienda, lo que excede el presente

trámite; debiendo en su caso instarse la liquidación de la comunidad de ganancias y sus incidencias de estimarlo pertinente. Repárese que con fecha 29.9.2019 (fs. 330) este tribunal requirió al actor que precisara con exactitud los términos de lo peticionado (adjudicación o atribución del uso) y el actor precisó que requería la atribución en los términos del art. 443 del CCC (fs. 338); a lo que se le imprimió trámite en los presentes (1.7.2020, fs. 348).

Efectuada esta aclaración y trabada la litis en los términos referidos, resulta entonces que las cuestiones radican en determinar si procede la atribución del uso de la vivienda familiar solicitada por el ex cónyuge o en su caso la fijación de una renta compensatoria a su favor y a cargo de la ex cónyuge, y el cambio del cuidado personal de la hija, el cual si bien peticiona continúe siendo compartido e indistinto requiere que la residencia principal sea la paterna en el inmueble cuya atribución de uso requiere y no ya la materna como en la actualidad.

Por su parte, la incidentada solicita el rechazo de la pretensión paterna y que se mantenga la atribución del uso de la vivienda familiar.

Finalmente, la representante complementaria dictamina que corresponde rechazar el pedido de modificación del cuidado personal y determinar la atribución del uso de la vivienda a favor de la progenitora, hasta la mayoría de edad de M. L.

Por razones de método se invertirá el orden del tratamiento de las incidencias, desde que la resolución que se adopte en relación a la residencia principal de la hija tendrá impacto en la decisión sobre la atribución del uso de la vivienda familiar y de la renta compensatoria.

3) EL CUIDADO PERSONAL Y EL INCIDENTE DE MODIFICACIÓN DE LA RESIDENCIA PRINCIPAL DEL HIJO:

El Código Civil y Comercial determina que, por regla, el cuidado personal de los hijos es compartido, debiendo el juez otorgar, a pedido de uno o ambos padres, el cuidado compartido del hijo con la modalidad indistinta, determinándose la residencia principal en el domicilio materno o paterno. Ello excepto que no sea posible o resulte perjudicial para el hijo (art. 651 del CCC). Por lo común, la práctica en la materia sigue, entonces, la voluntad de los padres plasmada en los acuerdos, atento que son ellos quienes están, en principio, en mejores condiciones de expresar lo que es más conveniente para sus hijos. Así, esa voluntad debe ser mantenida a manera de "status quo", mientras no existan causas o razones de entidad suficiente que aconsejen la modificación de la situación existente a fin de brindar a los niños, niñas y adolescentes el mayor grado de estabilidad posible.

En el caso el progenitor pretende modificar el acuerdo originario, pues si bien peticiona se mantenga compartido e indistinto requiere que la residencia principal de M. L. sea la paterna, en el inmueble en el cual actualmente habita la hija.

De las constancias de la causa surge que mediante la Sentencia de divorcio número 192 de fecha 19/06/2019, se homologó el acuerdo de las partes que reza "(...) *El cuidado personal de*

la niña será ejercido en forma compartida y en modalidad indistinta, compartiendo ambos progenitores las decisiones y distribuyéndose de modo equitativo las labores atinentes a su cuidado, por lo que la menor residirá de manera principal en el domicilio de la progenitora o donde lo constituyere en un futuro debiendo comunicar cualquier cambio en forma fehaciente al progenitor no conviviente. Del mismo modo el progenitor no conviviente deberá comunicar todo cambio de domicilio en forma fehaciente al progenitor conviviente con la hija. (...).

En dicha dirección, deberá analizarse entonces la prueba rendida y constancias acompañadas a fin de valorar la conveniencia o utilidad del cambio de residencia principal. De allí que deberá estarse al interés superior de la hija M. L. en el caso concreto.

Ahora, más allá de las ansias parentales, el norte a seguir -como en todas las medidas concernientes a las NNA que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos- una condición primordial a la que se tenderá será su interés superior. Dicho interés superior es entendido como el conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de su persona, prefiriéndose entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada analizada en concreto, ya que no se concibe un interés del NNA puramente abstracto. Al respecto, tal concepto excluye toda consideración dogmática para atender exclusivamente a las circunstancias particulares que presenta cada caso. Apunta a dos finalidades básicas: constituirse en una pauta de decisión ante un conflicto de intereses y en un criterio para la intervención institucional destinada a proteger al niño. Este principio proporciona un parámetro objetivo que permite resolver los conflictos de la persona menor de edad con los adultos que la tienen bajo su cuidado. De esta manera frente a un presunto interés del adulto se prioriza el del NNA.

Mas aun, tal interés debe integrarse necesariamente con el contexto fáctico de la presente causa, previa escucha activa de M. L. de 14 años de edad conforme su capacidad progresiva y garantizando el respeto de todos sus derechos.

En el punto se advierte que el incidentista no ha aportado elementos probatorios tendientes a demostrar el beneficio que el cambio de la situación de estabilidad actual importaría para su hija, cuyo interés superior debe primar, ni tampoco el perjuicio o gravamen que le acarrea a la adolescente continuar la convivencia principal con su progenitora como fuera acordado.

Así, en el punto resulta dirimente para la resolución lo informado por el CATEMU y la opinión vertida por la hija adolescente en oportunidad de ser oída en ejercicio de sus derechos. En cuanto a la primero repárese que la función de los equipos técnicos especializados trasciende la de los tradicionales informes escritos o verbales, porque la tónica de su actuación es también la propia de la justicia de protección o acompañamiento en la cual actúan. Por ende,

se torna necesario que estos expertos colaboren con los jueces en todo aquello que les sea requerido, asistiéndolos en la preparación y concreción de los actos que demanda de sus saberes especiales. En este aspecto la determinación del interés superior de M. L. hace necesaria la intervención de los especialistas que suministran elementos con relación a los temas cuya aprehensión resulta más allá de las ciencias jurídicas (CSJN autos VMN c SWF s/ Autorización, F. 333:1176). Ello se corresponde con la importancia del trabajo conjunto e interdisciplinario en los conflictos de familia, los que presentan variadas aristas que no pueden abordarse solamente desde la óptica jurídica (art. 706, inc. b. del CCC y art. 15, inc. 5 de la ley 10305) (Cámara de Familia de Primera Nominación Autos: “R. M. J. - Control de legalidad (Ley n.º 9944 - Art. 56) - Recurso de apelación” Auto nro. 62 07.06.2021).

Así, del informe acompañado con fecha 29/08/2023 por las Lics. P. y L. (CATEMU) luego de la entrevista personal mantenida en el tribunal y en presencia de la representante complementaria, se desprende que M. L. ha residido históricamente hasta la actualidad junto a su madre, compartiendo tiempos con su padre dos días en la semana y fines de semana de por medio. Se desprende que la adolescente mantiene con ambos progenitores un vínculo de afecto y calidez, logrando transitar por ambos hogares sin dificultades de significación. Valoran en este sentido como positivo el plan de parentalidad establecido desde pequeña. Agregan que se infiere un vínculo materno filial estrecho y de apego. Asimismo, refieren que, si bien el régimen comunicacional paterno filial se lleva a cabo, el progenitor muestra flexibilidad y comprensión ante requerimientos de M. de pernoctar con su madre. Por lo tanto, consideran conveniente no introducir modificaciones respecto a la situación actual.

Lo expuesto, resulta reforzado por la escucha directa de la adolescente a los fines de garantizar su opinión en la cuestión que lo involucra (arts. 655, 706 inc. c), 707 CCC, art. 15 inc. 10) del CPF). Del contacto personal mantenido advierto en M. un discurso claro y espontáneo, pudiendo expresar sus deseos y sentimientos, como así también relatar aspectos de su vida cotidiana, con un lenguaje acorde a su edad, sin precisiones. Es así que la hija da cuenta de los momentos que comparte con su madre, su cotidianeidad y que garantiza libremente el ejercicio de la coparentalidad y el contacto paterno filial. En este aspecto la representante complementaria destaca que de lo escuchado y valorado surge que el domicilio en cuestión, se constituye para M. L. en su “lugar”, su “centro”, donde tiene próxima sus amigas, sus mascotas, su colegio, sus vecinas, en el cual desarrolló toda su vida desde su nacimiento y se siente feliz. También considera que no debe modificarse el plan de parentalidad que las partes vienen desarrollando, el cual si bien consta de una organización con días y horarios, estos, conforme las necesidades de la adolescente se pueden ampliar o modificar y ambos padres acompañan dichos pedidos y necesidades.

De lo hasta aquí valorado no surgen elementos de prueba que justifiquen modificar el

cuidado personal de M. L.

Así, considero que a modo de status quo se impone mantener el domicilio principal materno de la adolescente con su progenitora, respetando y fortaleciendo el ejercicio responsable de la coparentalidad, por ser éste un derecho fundamental en la vida de la hija.

En este marco, a los fines de lograr una tutela judicial efectiva de los derechos del NNA, cuando las circunstancias del caso advierten sobre la necesidad de atender sus expresiones, es responsabilidad de los magistrados adoptar una decisión que, al contemplarlas, conjugue de la mejor forma posible todos los intereses en juego sobre la base de parámetros sustentados en una razonable prudencia judicial y teniendo en miras que es la conveniencia del niño (CSJN 1813/2018/RH1 P. B., E. G. c/ B., K. E. s/ medidas precautorias. Bs. As., 7.10.21). En esta dirección, considero que, tal como sostiene la Representante Complementaria, de momento -en atención al principio de la realidad y de estabilidad- no se encuentran dadas las condiciones para modificar el cuidado personal de M. L. en la forma solicitada por el progenitor.

Por lo demás, corresponde señalar que las decisiones relativas al cuidado de los hijos son, de hecho, circunstanciales o, al menos, siempre están sujetas a verse modificadas (Herrera, Marisa, Comentario al artículo 653 del Código Civil y Comercial de la Nación, ps. 367 y ss. En: Código Civil y Comercial de la Nación Comentado. Tomo IV. Arts. 594 a 723. Director: Ricardo Luis Lorenzetti, Rubinzal – Culzoni – Santa Fe, 2015), con lo que, lo hoy decidido puede ser revisado conforme las partes así lo requieran, instando siempre a los progenitores a ejercer responsablemente la responsabilidad parental que detentan, acompañando y escuchando a su hija en este camino hacia la autonomía, reconociendo sus necesidades y deseos y propiciando acuerdos que aporten estabilidad y contención a su hija.

En virtud de lo expuesto corresponde rechazar el incidente de modificación del cuidado personal de la hija adolescente interpuesto por el progenitor J. L. O.

4) LA ATRIBUCIÓN DEL USO DE LA VIVIENDA FAMILIAR Y EL PEDIDO DE RENTA COMPENSATORIA:

Previo a entrar al análisis de la cuestión debatida y procurando definir el marco teórico que englobe el planteo formulado, debemos poner de resalto que la protección de la vivienda es uno de los ejes centrales del ordenamiento jurídico de protección a los derechos fundamentales y, una de las maneras de protección prevista, es a través de la atribución del uso de la vivienda que fue sede del hogar familiar (art. 443 del CCC). Esta atribución (del derecho de uso) trae aparejada una restricción al derecho de propiedad que tiene como fundamento a la solidaridad familiar, pues lo que se busca es proteger al más vulnerable, pero debiéndose evaluar las circunstancias en cada caso para determinar la procedencia de la atribución, el plazo de duración y en su caso, los efectos, tal como el pedido de

establecimiento de una renta compensatoria por el uso del inmueble al ex cónyuge a quien no se le atribuya la vivienda (art. 444 del CCC).

En autos, el incidentista peticiona se le atribuya el uso de la vivienda familiar como un efecto del divorcio, atento no haberlo acordado en el convenio regulador, y la fijación de un canon locativo o renta compensatoria a cargo de la ex cónyuge hasta tanto se le atribuya el uso.

Repárese que para la procedencia de la atribución del uso de la vivienda familiar como efecto derivado del divorcio, la norma no distingue frente al carácter propio o ganancial que detente el inmueble; sino que sólo es necesario que al menos uno de los cónyuges sea titular de algún derecho que implique su uso o goce (CF2NCba en autos: “R, C D C/ O, M V- DIVORCIO VINCULAR- CONTENCIOSO- CUERPO DE APELACIÓN” (EXPTE. N° 7476767), auto n.º 160, del 14/11/2018).

Del análisis del caso surge que los comparecientes se encuentran divorciados conforme Sentencia número 192 de fecha 19/06/2019, que declara extinguida la comunidad de ganancias con retroactividad al 10/11/2014. A su vez, obra copia del fichón registral en un 100% a favor de J. L. O., de estado civil soltero, adquirido mediante escritura de fecha 24/06/2004 (fs. 331). De allí que se acredita el derecho sobre el inmueble independientemente de la discusión que las partes podrán efectuar en torno a los aportes que pudieran haber realizado por la vía pertinente, lo que como se adelantó excede el marco del presente incidente.

Por otra parte, no se encuentra controvertido que la vivienda referida sita en calle E. C, de la ciudad de V. A. ha sido sede del hogar conyugal, y luego fue atribuida de manera provisoria a A. S. E. junto a la hija en común del otrora matrimonio manteniéndose en los hechos tal situación hasta la fecha. Así, mediante decreto fundado de fecha 05/09/2018, se resolvió: “...**2º) Mantener provisoriamente la situación habitacional actual de la Sra. A. S. E. y su hija M. L. O. en el inmueble que fuera sede del hogar conyugal, debiendo las partes ocurrir a los fines de la atribución que correspondiere en definitiva por la vía de conocimiento pertinente (Art. 75 de la Ley 10.305).**”

En tal contexto corresponde adentrarse al análisis de las pautas de atribución del uso de la vivienda familiar expresamente enumeradas en el art. 443 del CCC para la procedencia, plazo de duración y efectos.

Llegados a este punto resulta dirimente señalar que, si bien el orden de las pautas que refiere el art. 443 CCC no debería indicar preeminencia de una sobre otra, no cabe duda de que quien quede a cargo del cuidado de los hijos tendrá un derecho preferente a solicitar la atribución del uso de la vivienda y ésta será una pauta importante a tener en cuenta (Bueres, Alberto J., dirección, «Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial», Editorial Hammurabi, 2016, T. 2, Arts.401 – 723,

pág.148/149).

La persona a quien se le atribuye el cuidado de los hijos representa el criterio mayoritario de todas las decisiones donde se resuelve la atribución del hogar y se traduce en la protección del grupo familiar más numeroso (Rivera, Julio César y Medina, G., Directores, "Código Civil y Comercial de la Nación Comentado", Ed. La Ley, 2014, v.2, pag. 91).

En esta inteligencia, autorizada doctrina ha dicho que: "...La existencia de hijos incide y funciona como una pauta específica, pero no la única, que se deberá evaluar ante el reclamo de fijación judicial de la atribución, pues las necesidades habitacionales de los hijos y las dificultades que pudiera implicar para aquel de los progenitores que permanece al cuidado de los hijos son condiciones fundamentales, tanto para determinar la procedencia como la duración y los efectos que tal atribución provocará..." (Molina de Juan, Mariel, comentario al art. 443 del Código Civil y Comercial de la Nación, en "Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014", Directoras Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Nora Lloveras, Rubinzal Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, Tomo I, pág. 489).

En el caso, mediante Sentencia número 192 de fecha 19/06/2019 se resolvió homologar el acuerdo arribado por las partes de manera compartida e indistinta con residencia principal en el domicilio de la progenitora, modalidad que en la presente resolución se mantiene, de allí que el presente pedido en relación a la atribución del uso de la vivienda, encuadra en el art. 443 inc. a) del CCC.

En cuanto a la persona que está en situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda por sus propios medios (art. 443 inc b) del CCC) de autos surge que la progenitora además de asumir mayores tareas de cuidado cotidiano respecto a su hija (lo que tiene un valor económico) se desempeña como pedicura y niñera por hora de manera informal. A su vez, el progenitor O. se desempeña actualmente como mecánico, arreglando chasis de automotores, con horarios variados y se encuentra viviendo junto a su madre, en una propiedad de esta, lo que implica que no tiene que afrontar el costo de un alquiler, y que ha podido resolver este aspecto habitacional. De allí que tal como lo asevera la representante complementaria, no ha quedado acreditado que la progenitora cuente con ingresos suficientes a fin de proveerse una vivienda, de allí que se vería en una gran dificultad si tuviera que conseguir una vivienda para alquilar y vivir junto a M. L.

Máxime si se advierte que la cuota alimentaria vigente para la hija (resolución del 05/06/2018) y a cargo del progenitor equivalente al 35% del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que no permite inferir que pueda solventar parte de una locación sin desatender otras necesidades básicas de la hija. Ello sin soslayar que también es a cargo del progenitor la obra social, matrícula y cuotas escolares. En este aspecto que se advierte que el aporte alimentario paterno necesariamente se completa con el rubro habitación que se ha mantenido hasta la

fecha.

Por lo demás, el incidentista tampoco ha demostrado en modo alguno encuadrar en el inciso b referido, ni ha efectuado referencias en relación al estado de salud y edad de los ex cónyuges ni los intereses de otras personas que integran el grupo familiar (incs. c y d) a los fines de meritar la procedencia de la atribución a su favor.

De allí que en coincidencia con lo dictaminado por la representante complementaria, estimo que debe rechazarse el pedido de atribución del uso de la vivienda por parte del ex cónyuge y, en consecuencia, atribuir el uso de la vivienda que fue sede del hogar conyugal a A. S. E.

Ahora bien, al analizar la duración de la atribución del uso de la vivienda familiar, la doctrina enseña que se trata “de un derecho de tipo temporal, pues implica una fuerte restricción al dominio que requiere una limitación temporal precisa. En la tensión subyacente entre el derecho sobre el inmueble del ex cónyuge a quien no se le atribuye el uso del mismo y el principio de solidaridad familiar, que obliga a tolerar esa restricción en función de la mayor vulnerabilidad de quien fuera su cónyuge, la fijación de un plazo funciona como una herramienta de equilibrio: ni el ex cónyuge debe soportar indefinidamente la limitación de sus derechos, ni quién se beneficia con la atribución del uso de la vivienda ‘resuelve’ su problema habitacional en forma definitiva” (Pellegrini, María Victoria en Aída Kemelmajer de Carlucci, Marisa Herrera, Nora Lloveras. Directoras. Tratado de Derecho de Familia según el Código Civil y Comercial de 2014. Rubinzal Culzoni Editores. Santa Fe, 2014. Tomo I, comentario al art. 443, p. 497).

Por ello, a la hora de establecer la fijación del plazo de duración debe estarse a las circunstancias de cada caso particular, ya que sobre la cuestión no puede fijarse una regla o principio inmutable, en tanto el conflicto por su viabilidad exige el contralor puntual de las circunstancias que rodean cada caso traído a decisión.

En el caso de autos, estimo ajustado a derecho que la atribución del uso se mantenga mientras la ex cónyuge continúe residiendo con la hija M. L. y hasta que la adolescente cumpla los 18 años de edad, lo que acontecerá el día 9.12.2027. En la actualidad, M. L. tiene 14 años de edad y considerando que la atribución del uso es un derecho temporario, lo resuelto permitirá garantizar el rubro habitacional de la hija durante la menor edad y sin generar una limitación al derecho de dominio irrazonable para el progenitor. Es que debe privilegiarse el interés superior de M. L. que vive con la progenitora (art. 3, párrafo primero, de la Convención sobre los Derechos del Niño) privilegiándose su crecimiento y desarrollo en un ámbito estable, no perdiendo de vista que la vivienda integra la obligación alimentaria a cargo de los progenitores.

Por lo demás, resta pronunciarme sobre el pedido de fijación de una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor de O., esto es, del ex cónyuge a quien no se le atribuye el uso de

la vivienda en los términos del art. 444 del CCC y a cargo de la ex cónyuge a quien se le atribuye.

Es que conforme lo dispuesto por los arts. 443 y 444 del CCC, la atribución del uso de la vivienda familiar se establece como uno de los efectos del divorcio, y a pedido de parte interesada, el juez puede establecer una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del cónyuge a quien no se atribuye la vivienda.

Al respecto se ha sostenido que la posible fijación de una renta debe ser valorada a la luz de las constancias de la causa, del grupo familiar y desde una visión integral e interpretación evolutiva (art. 1 y 2 del CCC) que contemple la imperativa mirada de género (CF2NomCba, en autos: “R., C. D. c/ O., M. V. – Divorcio Vincular – Contencioso – Cuerpo de Apelación”, Auto N° 160, del 14/11/2018).

Es en tal contexto que se impone valorar no sólo cuestiones relativas al derecho de propiedad (esto es si es un bien propio o ganancial, en condominio, y en su caso porcentajes) o al contrato de locación, por ejemplo (art. 443 del CCC), sino también existiendo hijos menores de edad con derecho alimentario, corresponde meritarse especialmente la clase y modalidad del cuidado personal, régimen de contacto o plan de parentalidad, cuota alimentaria establecida, y en general los intereses de otras personas que integran el grupo familiar; así como las posibilidades económicas de la persona a la que se ha atribuido el uso de la vivienda que fue sede del hogar conyugal a los fines de afrontar el pago de una renta compensatoria así como también si quien la requiere puede proveerse una vivienda, edad y estado de salud, estado del proceso de liquidación de la comunidad de ganancias, entre otros aspectos.

De las constancias de la causa ya examinadas surge que se trata de una vivienda de propiedad del incidentista y que no es utilizada de manera exclusiva por la ex cónyuge sino que es la sede de la vivienda familiar cuyo derecho de uso le ha sido atribuido teniendo especialmente en cuenta que en ella habita y tiene su centro de vida la hija del otrora matrimonio, quien tiene su residencia principal junto a su progenitora en dicha vivienda y con un régimen de contacto paterno filial.

Ahora bien, si ha mediado atribución del uso de la vivienda a la ex cónyuge y el inmueble es ocupado por ella y los hijos con derechos alimentarios contra quien reclama el canon se ha sostenido que resulta distinta la valoración de la prueba que corresponda realizar con relación al canon locativo por el uso y goce del inmueble ganancial (Sojo, Agustín, Código Civil y Comercial de la Nación y normas complementarias. T. 2. Artículos 401 a 723, Hammurabi, Bs. As., 2016, comentario al art. 484 del Código Civil y Comercial de la Nación, p. 484). Ello por cuanto el rubro habitación integra la obligación alimentaria de los progenitores.

Desde la jurisprudencia se sostiene que si el hijo menor de edad vive con la madre en el inmueble, la fijación del canon resulta improcedente (Cám. Civ. Com. Lab. y Min. General

Pico, Sala B. in re: “B., M. O. c/ C., V. P. s/ liquidación de la comunidad de bienes” de fecha 30/05/2018. Cita digital: IUSJU029616E consultado el día 14/08/2018). En dicho pronunciamiento se señaló que “en el caso que nos ocupa emerge un dato dirimente para denegar la procedencia del reclamo y, en consecuencia, para desestimar el planteo recursivo: la accionada ocupa la vivienda familiar de calle xx nº xxx junto a la hija menor de edad que quedó bajo su cuidado, es decir, no efectúa un uso y goce exclusivo del bien”.

No obstante ello, tal como lo afirma la representante complementaria, a la hora de decidir sobre la fijación del canon en casos como el presente, adquiere importancia la referencia a la cuota alimentaria vigente a favor de la hija y la demostración de que la ex cónyuge que reside de manera principal con la hija menor de edad se encuentra en condiciones de afrontar el canon o renta requerida por el uso de la vivienda.

De autos surge que la cuota alimentaria a cargo del alimentante en el 35% del Salario Mínimo Vital y Móvil, lo que deriva en un monto de \$82010.29 e implica un monto diario aproximado de \$2733.67, más el pago de obra social, matrícula y cuota escolar. De dicho cálculo surge a simple vista que de tener que destinarse parte de dicha cuota a los fines de cubrir la vivienda para la hija quedarían insatisfechas sus necesidades alimentarias básicas.

Llegados a este punto resulta dirimente considerar la situación económica en la cual se encuentra la ex cónyuge incidentada a fin de afrontar el pago de la renta compensatoria solicitada. En autos, no se ha producido prueba alguna tendiente a acreditar dicho extremo y por el contrario ya se sostuvo que la progenitora se encuentra en una situación económica más desventajosa para proveerse de una vivienda.

En tal contexto global, e independientemente de que tampoco se ha rendido prueba tendiente a la tasación del valor del alquiler del inmueble pretendido, de establecerse un monto en concepto de renta compensatoria podría finalmente incurrirse en una ficción por cuanto sería cubierto con el mismo aporte alimentario que realiza el progenitor peticionante, restituyendo la progenitora parte de ese dinero en concepto de renta por el uso de la vivienda familiar (CF2Nom.Cba, Auto 107, t. 2, 2.9.19 “Incidente de renta compensatoria en autos: “A, D O C/ B, G K - Divorcio vincular – Contencioso – expte. 2715185” – Recurso de apelación - (Expte. Nº 6587024)”.

En virtud de lo expuesto y ante la orfandad probatoria, corresponde rechazar el incidente de fijación de una renta compensatoria por el uso del inmueble a favor del ex cónyuge a quien no se le atribuye.

5) LA SOLUCIÓN QUE SE PROPICIA:

En atención a lo expuesto, en consonancia con lo dictaminado por la Representante Complementaria corresponde:

- 1) Rechazar el incidente de modificación del cuidado personal de la hija adolescente**

interpuesto por el progenitor J. L. O.

2) Rechazar el incidente de atribución del uso de la vivienda familiar y de la fijación de una renta compensatoria por el uso del inmueble incoado por el J. L. O., y, en consecuencia, atribuir el uso de la vivienda familiar sita en calle E. C., de la ciudad de V. A. a la ex cónyuge A. S. E. mientras resida junto con la hija adolescente M. L. O. y hasta que la misma adquiera la mayoría de edad, lo que acontecerá el día 9 de diciembre de 2027.

6) LAS COSTAS Y LOS HONORARIOS PROFESIONALES:

a) Las costas por la actuación relativa al incidente de modificación del cuidado personal se imponen por el orden causado. En efecto, estimo que la cuestión queda atrapa en el segundo párrafo del art. 130 CPC, ello atento la “naturaleza de la cuestión debatida en autos” y la “primacía del interés superior del niño”. Tal soporte argumental justifica suficientemente la solución de imponer las costas por su orden. Lo resuelto importa la aplicación del principio según el cual en las cuestiones no patrimoniales de familia no corresponde imponer las costas con fundamento en la derrota. Ello es así pues en estos casos la intervención del juez es una carga común necesaria para componer las diferencias entre las partes, precepto que no es sino una aplicación del segundo párrafo del art. 130 del CPCC (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G. “Condena en costas en el proceso civil”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1998, párraf. 218, pág. 450). Al respecto es tradicional la doctrina que sostiene en la materia que -en principio- no debe haber condena en costas relacionadas con la discusión sobre el cuidado y régimen de comunicación de los hijos menores de edad pues entre quienes procuran ejercer esa función, al tiempo de decidirse la cuestión, se ha de atender a lo que mejor convenga al interés de los hijos (Cámara de Familia de segunda Nominación in re: “B., C. R. – F. L., L. S. – Divorcio Vincular– No Contencioso–Recurso de Apelación Expte. N° 237732”, Auto N° 210 del 22/12/2014; “A. B. D. K., M. E y otro - Solicita Homologación - Recurso de Apelación”, Auto N° 69 del 02/05/2016, entre muchos otros). Y si bien dicha máxima no es absoluta, no puede soslayarse que en las cuestiones familiares la suerte de la materia de costas no siempre va de la mano de la derrota, sino que grava solamente situaciones extremas en que la recalcitrancia, el capricho, la incordia gratuita o la simple tozudez, desnudan una conducta reprochable, que obliga el dispendio jurisdiccional inútil o el desgaste gratuito de las partes (C. Apel., Civ. Com., B. Blanca, Sala I, 2/5/89, ED, 136-522, citado en Loutayf Ranea, Roberto G., ob. cit., págs. 450/451), lo que no se evidencia en los presentes. En consecuencia, corresponde imponer las costas por el orden causado y no regular los honorarios profesionales de los abogados C. M. M., M. A. R. y L. M. C., en virtud de no haber mediado petición expresa y a tenor de lo dispuesto por el artículo 26 interpretado en sentido contrario del Código arancelario.

b) En relación al incidente de atribución del uso de la vivienda familiar y fijación de renta

compensatoria, conforme al resultado al que se arriba, las costas se imponen al vencido, J. L. O. (art. 130 del CPCC).

A los fines de determinar el valor del juicio, se advierte que la atribución del uso de la vivienda, no tiene un contenido económico propio, y en cuanto a la fijación del canon locativo no se ha producido prueba alguna, por lo que puede recurrirse a los valores de referencia (art. 32 inc. 3 del CA). En la especie, no se encuentran en autos tasaciones del valor locativo probable actual del inmueble, tan solo la mención del peticionante de \$9.500 (16.3.2020), por lo tanto, partiendo del mínimo legal (15 jus) que para esta clase de juicio prevé art. 36 del CA por la tramitación total en primera instancia y sin perjuicio de lo dispuesto por el art. 28 del CA, en atención a las pautas cualitativas del art. 39 incs. 1 y 5 y lo dispuesto por los arts. 31, 36 y 69 del CA, se estima ajustado a derecho regular los honorarios profesionales del letrado M. A. R., en la suma de \$502312.20 equivalentes a 20 jus, esto es 5 jus más del mínimo legal, conforme su valor actual (1 jus: \$25115.61) por la actividad desplegada.

Por todo ello, lo dispuesto por las normas legales citadas,

RESUELVO:

- 1)** Rechazar el incidente de modificación del cuidado personal de la hija adolescente interpuesto por el progenitor J. L. O., con costas por el orden causado y no regular los honorarios profesionales de los letrados intervinientes C. M. M., M. A. R. y L. M. C., en virtud de no haber mediado petición expresa y a tenor de lo dispuesto por el artículo 26 interpretado en sentido contrario del Código arancelario.
- 2)** Rechazar el incidente de atribución del uso de la vivienda familiar y de la fijación de una renta compensatoria por el uso del inmueble incoado por el J. L. O., y, en consecuencia, atribuir el uso de la vivienda familiar sita en calle E. C., de la ciudad de V. A. a la ex cónyuge A. S. E. mientras resida junto con la hija adolescente M. L. O. y hasta que la misma adquiera la mayoría de edad, lo que acontecerá el día 9 de diciembre de 2027.
- 3)** Imponer las costas por el incidente de atribución del uso de la vivienda familiar y fijación de renta compensatoria al vencido, J. L. O. (art. 130 del CPCC).
- 4)** Regular los honorarios profesionales del letrado M. A. R., en la suma de \$502312.20, los que se encuentran a cargo de J. L. O., atento la imposición de costas oportunamente efectuada.
- 5)** No regular los honorarios profesionales de los abogados C. M. M. y L. M. C., en virtud de no haber mediado petición expresa y a tenor de lo dispuesto por el artículo 26 interpretado en sentido contrario del Código arancelario.

Protocolícese, hágase saber y dése copia.

Texto Firmado digitalmente por:

SQUIZZATO Susana Maria

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA

Fecha: 2024.07.25